SENTENÇA

Vistos, etc.

Lucia Helena Santos de Almeida, qualificada na petição inicial, propôs, sob os auspícios da justiça gratuita, **Ação de Obrigação de Fazer** contra **Hapvida Assistência Médica LTDA,** igualmente qualificada no exórdio, alegando em síntese que é beneficiária de plano de saúde ofertado pela requerida e está em dia com o pagamento das mensalidades.

Alega que foi diagnosticada com carcinoma lobular invasivo na mama, grau 2, metastático para os ossos e o médico assistente constatou a piora do quadro com o aumento da taxa de marcador CA 15-03, mesmo após a realização de procedimentos cirúrgicos e vários meses de tratamento com outros medicamentos.

Relata que o médico assistente prescreveu, então, o tratamento com o uso do medicamento *Kisqali* (Ribociclibe), sendo indicado 03 comprimidos de 200mg uma vez ao dia, por 21 dias, totalizando um ciclo de 28 dias, associado ao medicamento Fulvestranto 250mg (2 ampolas) a cada 28 dias.

Sustenta que a requerida negou a autorização e cobertura para o tratamento, sob a alegação de que o medicamento Ribociclibe tem cobertura obrigatória desde que observada a diretriz de utilização da ANS, mas, segundo a requerida, o quadro da autora não se enquadra na hipótese.

Requereu, então, a concessão da tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear o tratamento com o uso dos medicamentos prescritos pelo médico assistente.

No mérito, pugnou pela total procedência da ação com a consequente confirmação da tutela e condenação da promovida a custear as despesas com o uso do medicamento *Kisqali* (Ribociclibe) associado ao medicamento Fulvestranto 250mg (2 ampolas), bem

como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Instruíram a inicial diversos documentos, entre eles relatórios médicos (Ids nº 92180594 e nº 92180598) e comprovante da negativa de cobertura (Id nº 92180601).

Decisão concessiva da tutela ao Id nº 92219999.

Devidamente citada, a ré apresentou pedido de reconsideração ao Id nº 93103570 e comprovou o depósito no importe de R$ 6.000,00 (Id nº 93768746).

Rejeitado o pedido de reconsideração em decisão proferida ao Id nº 93382278.

A requerida apresentou também contestação ao Id nº 94271081, instruída com documentos, na qual sustenta a legalidade da negativa, em virtude da taxatividade do rol da ANS e das diretrizes de utilização; afirma que o medicamento prescrito para a autora tem cobertura obrigatória para o "*tratamento de pacientes com câncer de mama localmente avançado ou metastático, receptor hormonal (RH) positivo e receptor para o fator de crescimento epitérmico humano tipo 2 (HER2) negativo, em combinação com um inibidor*", mas o caso da autora apresenta resultado de receptor hormonal positivo, porém com proteína do HER-2 com score 2+, não se enquadrando nas diretrizes de uso do medicamento. Requer, por fim, a improcedência dos pedidos.

Alegações acerca do descumprimento da tutela aos Ids nº 93049876, nº 93303842, nº 93925038, nº 94689577, nº 96574227, entre outras.

Determinação de bloqueio de valores por meio do Sisbajud porque caracterizado o descumprimento (Id nº 95326123)

Réplica ao Id nº 96575988, instruída com documentos.

Nova decisão sobre o descumprimento da tutela ao Id nº 96885970.

No curso do processo houve prestação de contas pela parte autora referente à compra dos medicamentos, por exemplo aos Ids nº 98111194 e nº 103077266.

Intimadas para se manifestarem sobre a necessidade de produção de outras provas (Id nº 96885970), a requerida informou não ter provas a produzir (Ids nº 98930133) e a parte autora não se manifestou sobre a matéria.

A requerida interpôs agravos de instrumentos, distribuídos sob os nº 0020664-38.2021.8.17.9000 e nº 0004804-60.2022.8.17.9000, contra a decisão que deferiu a tutela e aquela que rejeitou o pedido de reconsideração, respectivamente, aos quais foi negado provimento.

Ao Id nº 117054927 a autora requerer a renovação da tutela para estender o tratamento por mais de 12 meses e, após determinação deste Juízo (Id nº 120130989), apresentou novo laudo médico ao Id nº 120502380.

Intimada para se manifestar sobre o pedido de renovação da tutela, a requerida permaneceu inerte (Id nº 121147701).

Assim vieram-me os autos conclusos.

É o que importa relatar. Passo à decisão.

Cabível o julgamento antecipado da lide, nos moldes previstos no artigo 355, inciso I do CPC, por versar a presente ação, predominantemente, sobre questão de direito, sendo desnecessária a produção de prova complementar, mormente quando as partes informaram não ter provas a produzir.

São fatos incontroversos que a autora é beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida e que ela está adimplente com o pagamento das mensalidades por ocasião do ajuizamento da ação, pois a negativa de cobertura foi fundamentada, exclusivamente, pela exclusão de cobertura.

Por outro lado, a documentação que instruiu a petição inicial, principalmente o laudo acostado ao Id nº 92180598, comprova que a autora é portadora do grave problema de saúde declinado na petição inicial (carcinoma lobular invasivo), bem assim que o médico assistente prescreveu o tratamento com o uso da medicação *Kisqali* (Ribociclibe) associado ao medicamento Fulvestranto 250mg (2 ampolas), em razão da progressão da doença mesmo com a realização de procedimentos cirúrgicos e uso de outros medicamentos.

Em se tratando de medicamentos tidos pelo profissional de saúde como imprescindíveis ao caso da autora e, por via de consequência, ao êxito do tratamento e, como tal, à manutenção da saúde do beneficiário do plano – objetivo este final, frise-se, do próprio contrato celebrado – a necessidade de cobertura é inquestionável, não competindo a requerida fazer juízo de valor sobre sua utilidade ou não.

O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do medicamento considerado essencial, pelo médico assistente (STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1760229 / PR, 4ª Turma, 21/06/2019; AgInt no AREsp 1.003.826/MG, 4ª Turma, DJe de 9/2/2017; AgInt no AREsp 949.765/SP, 3ª Turma, DJe de 19/12/2016; AgRg no REsp 1.325.733/DF, 3ª Turma, DJe de 3/2/2016; AgRg no AREsp 733.825/SP, 4ª Turma, DJe de 16/11/2015).

O medicamento solicitado pelo médico da autora é registrado na Anvisa e a patologia cujo medicamento solicitado busca tratar está no rol de cobertura mínimo estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, portanto, de cobertura obrigatória, *ex vi* do artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, estando ela listada na Classificação Internacional de Doença – CID, sob o código C50.9.

No caso em comento, a requerida sustenta que o caso da autora não atende as diretrizes de utilização fixadas pela ANS para o uso do medicamento *Kisqali* (Ribociclibe) e, por conseguinte, não haveria a previsão de cobertura obrigatória para o tratamento prescrito na hipótese de resultado de receptor hormonal positivo com proteína do HER-2 com score 2+, como no caso da autora.

Ocorre que o laudo médico de Id nº 92180598 atesta ser a autora *"portadora de carcinoma lobular invasivo, grau 2, receptores hormonais positivos,* ***HER negativo****"*, quadro que se amolda perfeitamente à alegada diretriz de utilização da ANS:

Ribociclibe	Mama	Tratamento de pacientes, com câncer de mama localmente avançado ou metastático, receptor hormonal (RH) positivo e receptor para o fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER2) negativo, em combinação com um Inibidor de aromatase ou Fulvestranto. Em mulheres na pré ou perimenopausa, a terapia endócrina deve ser combinada com um agonista do hormônio liberador do hormônio luteinizante (LHRH).

É verdade que o relatório médico acostado ao Id nº 92180594 indica tratar-se de HER2 score 2+; no entanto, nele consta a informação de que o resultado **é duvidoso** e, portanto, não cabe ao plano de saúde interpretar o resultado/diagnóstico como se a proteína fosse positiva sem que tenha sido comprovado com a repetição do exame.

O médico assistente, que a acompanha todo o tratamento da autora, atestou, com base na análise clínica e exames, ser o caso da autora de *receptores hormonais positivos, com HER negativo*, a prova em contrário caberia, então, ao plano de saúde, mas não o fez.

Por outro lado, a autora demonstrou, mediante a apresentação dos documentos acostados aos Id nº 117056649 e nº 120502380, que a utilização dos medicamentos associados, após concessão da tutela, gerou significativa melhora no estado de saúde, garantindo uma maior sobrevida à autora, o que corrobora o diagnóstico atestado pelo médico assistente.

Destaco que o portal Oncoguia traz informação esclarecedora acerca do resultado da imunohistoquímica, conforme trecho a seguir transcrito:

> *"Não está claro se um exame é mais preciso que o outro, mas o FISH é mais caro e os resultados demoram mais tempo para ficarem prontos. Muitas vezes, o exame imunohistoquímico é o primeiro a ser realizado.*
>
> *·Se o resultado da imunohistoquímica for 0 ou 1+, o câncer é HER2-. Esses tumores não respondem ao tratamento com medicamentos que têm como alvo a proteína HER2.*
>
> *·Se o resultado da imunohistoquímica for 3+, o câncer é HER2+. Esses tumores geralmente são tratados com medicamentos que têm como alvo a proteína HER2.*
>
> ***·Se o resultado da imunohistoquímica for 2+, o status HER2 do tumor não está claro. Isso geralmente implica na repetição do exame com FISH para definir o diagnóstico***. (*Texto originalmente publicado no site da American Cancer Society, em 20/09/2019, livremente traduzido e adaptado pela Equipe do Instituto Oncoguia*)[1]" (grifo nosso)

Não comprovado que o resultado da imunohistoquímica da autora foi 3+, não pode o plano simplesmente concluir trata-se de câncer HER2+ com o claro objetivo de excluir o tratamento da cobertura contratual.

Como se não bastasse o acima exposto, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de ser *"abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"* (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma,

julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

Registra-se, ainda, ciência quanto à recente decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 08.06.2022, que *"entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista***[2]***"*.

No entanto, em decisões posteriores ao referido julgado, o STJ reconheceu que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não tem relevância à análise do dever de cobertura de medicamentos para o câncer.

Nesse sentido:

> *PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento do* ***medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali)****, necessário para tratamento oncológico. 2.* ***Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"*** *(AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário 3.* ***Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes.*** *4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2030294 / MS, 3ª Turma, Ministra Nancy Andrighi, DJe 24.11.2022)*
>
> *CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3,*

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. ***Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.*** *3. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação. Incide a Súmula n.º 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.001.658/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)*

Impende destacar, por fim, que a Lei nº 14.307, de 03/03/2022, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades, sendo esse precisamente o caso dos autos.

Demonstra-se, portanto, ser o tratamento prescrito para a autora de cobertura obrigatória pelo plano de saúde e, por conseguinte, é abusiva a negativa de cobertura.

- Aplicação de multa pelo descumprimento:

Ao Id nº 92219999 foi concedida a tutela de urgência para compelir a requerida a autorizar e custear, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento da autora com o uso do medicamento *Kisqali* (ribociclibe), conforme prescrição do médico assistente.

Para o caso de descumprimento foi fixada multa diária de R$ 2.000,00 limitado a R$ 30.000,00.

Não obstante ter sido devidamente cientificada em 08.11.2021 (Id nº 92364319), a requerida deixou transcorrer o prazo concedido (término - 15.11.2022) sem comprovar o cumprimento da obrigação.

Em que pese o descumprimento da decisão, no dia 25.11.2021, foi comprovado o depósito no importe de R$ 6.000,00 (Id nº 93768746), o que denota que agiu dentro do dever de cooperação, consoante preceitua o art. 3º do CPC.

Nesse contexto, cediço que o valor da multa pode ser reduzido ou majorado a depender das circunstâncias do caso concreto, mormente quando a demandada buscou mitigar os prejuízos do descumprimento.

Nesse contexto, entendo por fixar o valor da multa no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reis), valor esse que reputo proporcional e razoável para a situação em tela.

- Renovação da tutela:

A autora, ao Id nº 117054927, noticiou a eficácia e eficiência do tratamento realizado no curso do processo com o uso do medicamento *Kisqali* (ribociclibe) e informou a melhora expressiva do seu estado de saúde.

Requereu, por conseguinte, a renovação da tutela para estender o tratamento por mais 12 meses, juntando ao Id nº 120502380 novo laudo médico.

Como já exaustivamente fundamentado acima, o tratamento prescrito para a autora é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura.

O novo laudo médico acostado ao Id nº 120502380 demonstra o êxito do tratamento da autora com a medicação *Kisqali* (ribociclibe) e atesta a necessidade da continuidade do tratamento.

Ademais, apesar de devidamente intimada, a requerida não apresentou impugnação ao pedido de renovação da tutela e o TJPE confirmou integralmente as decisões proferidas ao Ids nº 92219999 e nº 93382278 (agravos de instrumento de nº 0020664-38.2021.8.17.9000 e nº 0004804-60.2022.8.17.9000).

Mantida, portanto, a probabilidade do direito da autora, bem como a urgência do caso, por ser a autora portadora de grave moléstia, é de rigor a renovação/manutenção da tutela para compelir a requerida a autorizar e custear o tratamento da autora com o uso do medicamento *Kisqali* (Ribociclibe) por mais 12 meses.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, **confirmo a tutela concedida ao Id nº 92219999** e **JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na petição inicial, resolvendo o processo com incursão no mérito,** para condenar a requerida a:

a) autorizar e custear o tratamento da autora com o uso do medicamento *Kisqali* (Ribociclibe), sendo indicado 03 comprimidos de 200mg uma vez ao dia, por 21 dias, totalizando um ciclo de 28 dias, associado ao medicamento Fulvestranto 250mg (2 ampolas) a cada 28 dias, conforme prescrições do médico assistente acostadas aos autos (Ids nº 92180598 e nº 120502380) e eventuais prescrições para o uso do referido medicamento posteriores a esta sentença;

b) pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à multa fixada na decisão de Id nº 92219999.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Tendo em vista a fundamentação acima, com fulcro no artigo 303 do CPC, **RENOVO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA,** determinando à requerida que autorize e custei, **no prazo de 03 (três) dias**, o tratamento da autora com o uso do medicamento *Kisqali* (Ribociclibe) associado ao medicamento Fulvestranto 250mg (2 ampolas) por mais 12 meses, conforme prescrito pelo médico assistente no novo laudo médico acostado Id nº 120502380, dando total cobertura.

Considerando que a requerida não comprovou a impossibilidade de custeio do tratamento por meio dos fornecedores que atendem a sua rede conveniada, com os quais mantém vínculo comercial e atento a possível remessa dos autos ao TJPE e/ou arquivo, o

cumprimento da decisão deverá ser realizado por meio da rede de conveniada e não por depósito judicial.

Para o caso de novo descumprimento fixo multa diária no importe de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Advirto, ainda, a requerida que em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo da multa acima fixada, poderá também ensejar a aplicação outras sanções processuais previstas na legislação, podendo caracterizar, inclusive, o crime de desobediência (art. 330 do CPB).

Intime-se a ré, **com urgência, através de mandado**, para cumprimento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Caso interposta(s) apelação(ões), intime(m)-se a(a) parte(s) contrária(s) para apresentar(em) contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao Eg. TJPE para julgamento.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Olinda, 22 de dezembro de 2022.

Eurico Brandão de Barros Correia

Juiz de Direito Auxiliar

---

[1] http://www.oncoguia.org.br/conteudo/cancer-de-mama-her2/10880/264/, acessado em 20.12.2022.

[2] https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx

Assinado eletronicamente por: EURICO BRANDAO DE BARROS CORREIA
22/12/2022 13:45:53
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 122242289

22122213455313400000119471189

IMPRIMIR GERAR PDF